

1500842-12.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... somente três. Confessa apenas o primeiro tráfico do qual já foi condenado em 2007, e desde então não traficou mais, negando assim os dois tráficos que os policiais hoje disseram que o prenderam. Não sabe o nome nem o endereço da moça para quem carregava os entulhos no dia dos fatos. Ia receber setenta reais para trabalhar para a moça, e quando a polícia chegou já estava com esse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500842-12.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/000602

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2117095/2021 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Edgleidson Nazare

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JOSE EDGLEIDSON NAZARE, qualificado às fls. 08 e 24/25, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 29 de abril de 2021, por volta das 15h45, na Passagem do Progresso, altura do n.º 219, Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 36 embalagens plásticas contendo 20,91g da droga cocaína, 23 embalagens plásticas contendo 3,75g da mesma droga, na forma de crack e 46 embalagens plásticas contendo 46,14g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 13/14 e laudo de constatação provisória de fls. 16/18, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fl. 72/74). Foi nomeado Defensor Público que apresentou defesa inicial às fls. 122/125. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 02/07/2021 (fls. 135/136) por incabível proposta de acordo de não persecução penal e certificada a notificação e a citação positiva do Réu as fls. 112 e 163.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. O julgamento foi convertido em diligência para a realização de exame de dependência químico toxicológico, à pedido do d. Advogado, cujo laudo pericial está juntado as fls.344/349, depois de muitas cobranças e interferências pessoais dessa juíza e da d. Promotora de Justiça, concluindo pela imputabilidade penal do réu.

Em memoriais o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo legal diante da grande quantidade de drogas e dos maus antecedentes criminais, entendendo ainda que deva preponderar a agravante da reincidência (fl. 51) sobre a atenuante da confissão, discordando da redução da pena, e de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, além da perda do valor apreendido (fls. 369/373).

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória por haver dúvida a ser revertida em favor do réu (fls. 378/384).

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede diante da imputabilidade penal do réu à prática do crime em tela, como atestado pelo perito oficial no laudo pericial de fls. 344/349, estando a materialidade delitiva estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, nos autos de constatação e no definitivo (fls.16/18 e 159/161, respectivamente), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls. 06 e 07), em diligência com viatura descaracterizada pela Rua do Progresso, altura do número 219- local conhecido como ponto de tráfico - visualizaram em atitude suspeita e com aparente nervosismo JOSÉ EDGLEIDSON NAZARÉ (indivíduo já preso pela mesma equipe em outra ocasião), motivo pelo qual realizaram a abordagem. Ao ser questionado pelos policiais, de pronto o réu confessou a prática do tráfico, indicando a localização das drogas, que se encontravam há aproximadamente um metro de distância. As drogas estavam acondicionadas em uma sacola amarela descartável, sendo apreendidos com o indivíduo: R\$30,00, além de 46 porções de uma substância de cor esverdeada aparentando ser maconha, 36 porções de uma substância de cor branca e sólida aparentando ser cocaína e por fim, 23 porções de uma substância petrificada aparentando ser crack.

Sob o crivo do contraditório esses policiais Cleber Matias e Marcus Faria reiteraram que na data da prisão foram com uma viatura descaracterizada até o ponto de tráfico. Avistaram o réu com uma bolsa em mãos, mexendo dentro dela. Foi abordado e constataram que no interior da bolsa térmica haviam os três tipos de entorpecentes, noventa invólucros totais. Com ele, na carteira, estava a quantia em dinheiro de oitenta e nove reais, que ele disse ser dele e não da venda. Ele alegou que estava no local como olheiro do tráfico apenas, e que seria seu primeiro dia, e ao final do dia ganharia cinquenta reais, mas era ele quem estava na biqueira, sozinho, parado, e com as drogas dentro de uma bolsinha que estava na mão dele. Reconhecem o réu, e segundo os parentes dele, o réu tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados. Chegaram a notar que o réu tinha algum problema mental, estava desconexo e agitado no dia dos fatos. O réu foi solto, e quinze dias depois ele foi preso novamente pelo mesmo crime, no mesmo local, pelos mesmos policiais, após uma denúncia anônima, quando o réu confessou estar vendendo as drogas. Não os

viram no local até então.

Questionado o policial Marcus a respeito de estar fazendo confusão entre as duas prisões do réu, ele respondeu que pode ser que sim, pois se deram num período de quinze dias só, tratando-se do mesmo réu, preso no mesmo ponto de venda de drogas, onde estava parado, sozinho, e em poder dos entorpecentes, mas nas duas oportunidades era ele quem traficava, pois não havia mais ninguém.

Tanto que o próprio réu, em juízo, também estava confuso com relação a quais fatos estava sendo inquirido, tanto que questionou se ia falar da primeira ou da segunda prisão. Dito que seria da segunda, respondeu que estava carregando entulho e os policiais acharam uma porção de maconha no entulho, e o colocaram dentro da viatura. Faz tratamento no posto de saúde onde mora, no Jardim Marilene. Toma oito remédios controlados e atualmente estão lhe dando somente três. Confessa apenas o primeiro tráfico do qual já foi condenado em 2007, e desde então não traficou mais, negando assim os dois tráficos que os policiais hoje disseram que o prenderam. Não sabe o nome nem o endereço da moça para quem carregava os entulhos no dia dos fatos. Ia receber setenta reais para trabalhar para a moça, e quando a polícia chegou já estava com esse dinheiro, alegando ter recebido antes de completar o trabalho. É uma pessoa consciente porque toma os remédios. Tem família, esposa e filho. Não sabe o motivo de estar sendo incriminado pelos policiais, e que só tinha maconha na sacola, que não estava consigo, e sabe disso porque os policiais a encontraram num entulho e mostraram o que havia dentro, só tendo visto maconha.

Contudo, em solo extrajudicial (fl.8), o réu havia confessado a traficância no local, alegando problemas psiquiátricos e dificuldades em encontrar um emprego lícito. Informou que ganhava a quantia de R\$50,00 por dia.

Diante do exposto acima, tem-se haver prova cabal a embasar a condenação, não apenas pela confissão extrajudicial do réu, embora não reiterada completamente em juízo, quando ele alegou que na sacola apreendida pelos policiais no entulho que carregava, só tinha maconha, mas não fez prova de nada disso, como lhe competia esse ônus, ou seja, de que no dia e hora dos fatos não estaria traficando e sim carregando entulho para uma moça, que sequer foi arrolada. Ainda, e em que pese os policiais tenham se confundido com relação aos fatos narrados nesses autos, tal confusão se deu porque haviam prendido o réu no mesmo local traficando, quinze dias antes, tanto que o próprio acusado questionou sobre qual dos tráficos era para ele responder. Segundo os policiais, era o réu, por eles reconhecido, quem estava parado na biqueira já conhecida, feito um poste, sozinho, com uma bolsa contendo drogas, além do dinheiro apreendido com ele quem, inclusive, confirmou extrajudicialmente, ser da venda dos narcóticos. Tudo sem prova contrária.

No mais, é certo que o laudo psiquiátrico produzido às fls. 344/349 foi conclusivo acerca do fato de que, em que pese tratar-se o réu de pessoa portadora de esquizofrenia, tal doença não turvou seu entendimento ou capacidade de determinar-se para a conduta delituosa (fl. 345), concluindo, portanto, pela sua plena imputabilidade.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas e sua grande quantidade 105 no total, o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (fl. 13), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, especialmente os maus antecedentes criminais do acusado como se demonstra

através da FA de fl. 55 (condenação pela 3ª Vara Criminal de Diadema, em 2007), assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (105 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência comprovada pela certidão criminal de fl. 51 (condenação em 2011, pela 2ª Vara Criminal de Diadema) a qual compenso com a atenuante da confissão que foi considerada também como prova a embasar a condenação, e que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), de modo que a pena resta inalterada nesta etapa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional fechado, considerando a quantidade da pena, e também a preponderância da natureza e da quantidade de droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019). E o que dirá em se tratando de reincidente.

Incabível, portanto, a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário). Ademais: Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime. (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião

Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. E ainda que descontado o tempo de prisão por esse processo, de um ano e sete meses dada à demora na juntada do laudo pericial, embora tenham sido reiteradas as cobranças da vinda dessa prova pleiteada pela Defesa, contando inclusive com contato telefônico pessoal da d. Promotora de Justiça e do juízo com o diretor do Instituto antes de se instaurar processo por desobediência, não há possibilidade de progressão de regime nem de recurso em liberdade ante a alta quantidade de reprimenda ora fixada.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC nº 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JOSE EDGLEIDSON NAZARE, qualificado às fls. 08 e 24/25, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Decreto a perda de numveário apreendido (fl.13), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA